

検察官の面前における供述を録取した書面についての刑事訴訟法第 321 条第 1 項第 2 号に関する次の 1 から 5 までの各記述のうち、判例に照らして正しいものはどれか。

1. 共同被告人は、被告人との関係においては、被告人以外の者であって、被害者その他の純然たる証人とその本質を異にするものではないから、共同被告人の検察官に対する供述調書は、同号にいう「検察官の面前における供述を録取した書面」に当たる。
2. 証人が公判廷において証言を拒絶した場合は、同号前段の「公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき」に当たらない。
3. 既に公判期日において証人として尋問された者に対し、検察官が、後の公判期日に提出することを予定して、その尋問内容と同一事項につき取り調べて作成した供述調書は、その後の公判期日において、その者が前記供述調書の内容と相反する供述をしても、同号後段にいう「前の供述」に当たらない。
4. 退去強制によって出国した外国人の検察官に対する供述調書については、同号前段のその供述者が「国外にいる」という要件を満たすので、常に、事実認定の証拠として許容される。
5. 同号ただし書の「前の供述を信用すべき特別の情況」は、供述がなされた際の外部的な事情のみを判断資料とすべきであり、この「特別の情況」を推知させる事由として、その供述内容を考慮することはできない。

1 正しい

最決昭27.12.11は、共犯である共同被告人の検察官に対する供述調書は、被告人に対する関係においては321条1項2号の書面とみるべきであるとする。したがって、本記述は正しい。

2 誤っている

最大判昭27.4.9は、321条1項2号の規定に供述者が供述することができないときとしてその事由を掲記しているのは、その供述者を裁判所において証人として尋問することを妨げるべき障害事由を示したもので、これと同様又はそれ以上の事由が存在する場合において321条所定の書面に証拠能力を認めることを妨げるものではないから、証人が公判廷で証言を拒絶した場合には、321条1項2号により、同人の検察官の面前における供述録取書を証拠とすることができるとして、321条1項2号前段を例示列挙と解している。したがって、証人が公判廷において証言を拒絶した場合は、同号前段の「公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき」にあたらないとする点で、本記述は誤っている。

3 誤っている

最決昭58.6.30は、「すでに公判期日において証人として尋問された者に対し、捜査機関が、その作成する供述調書をのちの公判期日に提出することを予定して、同一事項につき取調を行うことは、現行刑法の趣旨とする公判中心主義の見地から好ましいことではなく、できるだけ避けるべきである」としながらも、「右証人が、供述調書の作成されたのち、公判準備若しくは公判期日においてあらためて尋問を受け、供述調書の内容と相反するか実質的に異なった供述をした以上、同人が右供述調書の作成される以前に同一事項について証言をしたことがあるからといって、右供述調書が刑法321条1項2号にいう『前の供述』の要件を欠くことになるものではない」とする。したがって、同号後段にいう「前の供述」にはあたらないとする点で、本記述は誤っている。

4 誤っている

最判平7.6.20(百選80事件)は、321条1項2号が、供述者が国外にいるため公判で供述することができないときは検面調書に証拠能力を付与するものであることを確認しながらも、「右規定が同法320条の伝聞証拠禁止の例外を定めたものであり、憲法37条2項が被告人に証人審問権を保障している趣旨にもかんがみると、検察官面前調書が作成され証拠請求されるに至った事情や、供述者が国外にいることになった事由のいかんによっては、その検察官面前調書を常に右規定により証拠能力があるものとして事実認定の証拠とすることができるとすることには疑問の余地がある」とした。そして、退去強制によって出国した者の検面調書については、「検察官において当該外国人がいずれ国外に退去させられ公判準備又は公判期日に供述することができなくなることを認識しながら殊更そのような事態を利用しようとした場合はもちろん、裁判官又は裁判所が当該外国人について証人尋問の決定をしているにもかかわらず強制送還が行われた場合など、当該外国人の検察官面前調書を証拠請求することが手続的正義の観点から公正さを欠くと認められるときは、これを事実認定の証拠とすることが許容されないこともあり得るといわなければならない」として、例外を認めている。したがって、常に、事実認定の証拠として許容されるとする点で、本記述は誤っている。

5 誤っている

特信情況の判断資料につき、かつては証明力の問題としてその判断は裁判官の自由心証によるという考えもあったが、最判昭30.1.11(百選A37事件)は、証拠能力の問題であることを前提にして、「必ずしも外部的な特別の事情でなくとも、その供述の内容自体によってそれが信用性ある情況の存在を推知せしめる事由となる」としている。したがって、「特別の情況」(321条1項2号ただし書)を推知させる事由として、その供述内容を考慮することはできないとする点で、本記述は誤っている。